

1511382-96.2020.8.26.0071
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Marina Freire
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/06/2022
... policiais penais. Nesse sentido:

Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de agentes penitenciários.

1 - As provas -- depoimentos de agentes penitenciários e laudo de exame químico que confirma a natureza da substância encontrada com o réu -- são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes em estabelecimento prisional pelo réu.

2 - Os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
3ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1511382-96.2020.8.26.0071
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA
Réu:
PABLO ALEXANDRE GOMES VITAL

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

PABLO ALEXANDRE GOMES VITAL, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 14h35, nas dependências do estabelecimento prisional Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Eduardo de Oliveira Vianna" (CPP II), localizado na Rodovia Marechal Rondon, Km 353, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo 104,85 g do entorpecente conhecido como maconha, divididos em 18 porções, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 1/2), por decisão de fls. 71/72 foi determinada a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 88) e apresentou defesa prévia às fls. 92/93.

A decisão de fls. 99/101 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado (fl. 151-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que entendeu provados os fatos narrados na denúncia, bem como a materialidade e a autoria delitivas (fls. 155/158).

Em outro ângulo, a Defesa destacou a ausência de provas e de elementos a corroborar um édito condenatório, alegando que não restou demonstrada a existência de drogas no estômago do réu e que ele as expeliu. Assim, focada na insuficiência probatória e no princípio do in dubio pro reo, rogou pela absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação, sustentou e pleiteou a desclassificação do delito para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como fixação de regime inicial semiaberto (fls. 169/176).

Por despacho de fl. 181, o julgamento do feito foi convertido em diligência para juntada aos autos da Certidão Estadual de Distribuições Criminais, o que se deu à fls. 183/185.

O órgão ministerial reiterou suas alegações finais, ressaltando que a certidão acostada não indica ser o réu reincidente (fl. 201).

A Defesa, por sua vez, pleiteou seja aplicada, na fração máxima, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o réu é primário e não registra antecedentes criminais (fl. 206).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de tráfico de drogas.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição e apreensão de fl. 9, procedimento administrativo disciplinar de fls. 19/58, laudo toxicológico definitivo de fls. 59/63, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática do delito. Aduziu que na data dos fatos retornava ao estabelecimento prisional após trabalho externo e, ao ser submetido à vistoria no scanner corporal, agentes penitenciários lhe disseram que havia uma mancha suspeita em seu corpo, momento em que negou possuir qualquer objeto, todavia foi encaminhado a uma cela separada, recebendo informação de que ele seria averiguado. Acrescentou ter sido transferido a outro presídio depois de dez dias sem sequer ter sido acusado da prática nem recebido fotografias da droga. Negou ter vomitado porções de entorpecente no momento dos fatos (fl. 151-mídia).

O agente de segurança penitenciária Giovani dos Santos Cano relatou que o réu, ao

retornar do trabalho externo, foi submetido ao scanner corporal, quando então alguns objetos foram identificados no estômago dele. Mencionou que inicialmente o réu negou, afirmando que apenas havia se alimentado, no entanto, após receber a informação de que seria conduzido ao hospital, ele admitiu a ingestão de estupefaciente; ato contínuo, o réu foi encaminhado ao setor de inclusão, onde acabou expelindo as porções de droga. Esclareceu que os detentos são submetidos ao scanner corporal quando retornam de trabalho externo, bem como faz parte do procedimento fotografar drogas e objetos localizados (fl. 151-mídia).

No mesmo sentido, o agente André Luiz Ducatti narrou que, no dia dos fatos, o réu foi submetido ao body scanner após o retorno do trabalho externo, sendo constatados alguns objetos em seu estômago; ao ser interpelado, ele admitiu que havia engolido porções de maconha, momento em que foi conduzido a uma cela do setor de inclusão e, após alguns minutos, vomitou 18 invólucros plásticos contendo maconha (fl. 151-mídia).

Ao que se extrai das provas documental e oral colhidas nos autos, bem como observada a dinâmica dos fatos, não persistem dúvidas no tocante à responsabilidade do réu pela prática do delito de tráfico de drogas.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades “trazer consigo” ou “transportar”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Como se observa, os agentes penitenciários foram uníssonos e categóricos ao afirmar como se deram os fatos, haja vista que, na data dos fatos, os detentos retornavam ao estabelecimento prisional após trabalho externo e, no momento da revista pessoal, o réu foi submetido ao scanner corporal, tendo sido constatada substância anormal em seu estômago, posteriormente identificada como porções de maconha, após o réu as regurgitar.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos policiais penais revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte das testemunhas, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de serem policiais penais. Nesse sentido:

Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de agentes penitenciários.

1 - As provas -- depoimentos de agentes penitenciários e laudo de exame químico que confirma a natureza da substância encontrada com o réu -- são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes em estabelecimento prisional pelo réu.

2 - Os depoimentos prestados por agentes penitenciários, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados.

3 - Apelação não provida.

(TJDF. 2ª Turma Criminal. Apelação nº 0000788-15.2018.8.07.0001. Relator: Des. Jair Soares. Data do julgamento: 28 de fevereiro de 2019)

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com

fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes." (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei).

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu, revelando-se inverossímil sua versão no sentido de desconhecer a apreensão de entorpecentes, haja vista que o réu, após a constatação da presença de objetos suspeitos em seu organismo, foi conduzido pelas testemunhas a uma cela específica no setor de inclusão do presídio, onde acabou por vomitar as 18 porções de maconha apreendidas nos autos e fotografadas à fl. 63.

Da análise do laudo toxicológico definitivo de fls. 59/63, é possível observar que foram apreendidas 18 porções de maconha (104,85 g), a corroborar o exercício da traficância pelo réu.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade do produto apreendido (104,85 g de maconha, divididos em 18 porções) e a forma em que foi encontrado encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

De se notar que, embora o réu negue o tráfico, afirmando ser usuário, é certo que tal negativa não passou de uma tentativa para desclassificar o delito. Aliás, a alegação de ser usuário não alija a traficância. Muitos traficantes buscam como meio de defesa a desclassificação da infração penal. E, neste ponto, deve-se salientar não ser uma situação excludente da outra.

Ainda, por amor aos debates, sequer há se cogitar em crime impossível, diante da ineficácia absoluta do meio.

De fato, na hipótese dos autos, o crime se consumou no momento em que o réu levou consigo as porções de estupefaciente. Logo, não há se falar em ineficácia absoluta do meio e, consequentemente, crime impossível, porquanto o delito já estava consumado antes mesmo de os agentes penitenciários examinarem o réu.

Ademais, cabe salientar que a revista pessoal aos detentos não torna o meio absolutamente ineficaz, pois não se trata de procedimento infalível, destacando-se os inúmeros casos de apreensão de entorpecentes e aparelhos telefônicos já no interior das celas.

Por derradeiro, cumpre enfatizar que está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, já que o delito foi cometido nas dependências do estabelecimento prisional Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Eduardo de Oliveira Vianna" (CPP II de Bauru).

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, resta somente a fixação da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fls. 183 e 198: processo nº 0000286-80.2017.8.26.0616). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis.

Destarte, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa. Contudo, segundo a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, de sorte que a sanção fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500

dias-multa.

Na terceira fase, observada a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional, a sanção deve ser majorada em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

Por outro lado, não é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes do réu e seu histórico infracional (fls. 186/187).

Ainda, há demonstração de que ele se dedica a atividades criminosas, sendo de fundamental importância enfatizar que foi flagrado na prática delitiva enquanto cumpria pena por tráfico de drogas, como também a quantidade de entorpecente apreendido (104,85 g de maconha) revela a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 - PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

Dessa forma, ficam as penas mantidas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu PABLO ALEXANDRE GOMES VITAL à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

O réu respondeu ao processo em liberdade. Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA